

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7241/2549

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายชัชวาลหรือกุ่ม ภาวะคงบุญ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 133 ทวิ

ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีขึ้นไป และเป็นคดีทำร้ายร่างกาย เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี กรณีต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 133 ทวิ ซึ่ง กฎหมายกำหนดว่า ในการถามปากคำเด็กไว้ในฐานะผู้เสียหายให้แยกกระทำเป็นส่วนลับในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำ นั้นด้วย เมื่อปรากฏว่าพนักงานสอบสวนถามปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กต่อหน้า ร. มารดาผู้เสียหายเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่ามีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์และ พนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำนั้นกับมิได้ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้ บันทึกเหตุที่ไม่อาจรบกวนบุคคลอื่นดังกล่าวไว้ในสำนวนการสอบสวนตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 133 ทวิ วรรคท้ายด้วย การถามปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กที่พนักงานสอบสวนได้กระทำไปจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้น แต่ก็หาผลถึงขนาดทำให้การสอบสวนเสียไปทั้งหมด และถือเท่ากับไม่มีการสอบสวนในความผิด นั้นมาก่อนอันจะทำให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 120 ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 279, 295, 90 และให้บวกโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5023/2542 ของศาลแขวงพระนครเหนือ เข้ากับโทษในคดีนี้

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง, 279 วรรคสอง และ 295 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปี จำคุก 15 ปี และให้บวกโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5023/2542 ของศาลแขวงพระนครเหนือเข้ากับโทษในคดีนี้รวมจำคุก 16 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่าพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ กฎหมายบังคับเด็ดขาดว่าการสอบปากคำเด็กอย่างน้อยต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์คนหนึ่ง และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการสอบปากคำด้วยการที่พนักงานสอบสวนเพียงแต่สอบปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กต่อหน้านางรุ่งตะวัน ผู้เป็นมารดาเท่านั้น จึงเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีขึ้นไป และ

เป็นคดีทำร้ายร่างกายเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีด้วย กรณีจึงต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ ซึ่งกฎหมายกำหนดว่า ในการถามปากคำเด็กไว้ในฐานะผู้เสียหาย ให้แยกกระทำเป็นส่วนสัดส่วนในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอและ พนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำนั้นด้วย เมื่อปรากฏว่าพนักงานสอบสวน ถามปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กต่อหน้านางรุ่งตะวันมารดาผู้เสียหายเท่านั้น โดยไม่ ปรากฏว่ามีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการ ถามปากคำนั้นด้วยกับมิได้ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้บันทึกเหตุที่ไม่อาจรบกวนบุคคล อื่นดังกล่าวไว้ในสำนวนการสอบสวนที่บัญญัติไว้ในมาตรา 133 ทวิ วรรคท้ายด้วย การถามปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กที่พนักงานสอบสวนได้กระทำไปจึงเป็นการไม่ ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้น แต่ก็หาผลถึงขนาดทำให้การสอบสวนเสียไป ทั้งหมด และถือเท่ากับไม่มีการสอบสวนในความผิดนั้นมาก่อนอันจะทำให้พนักงาน อัยการไม่มีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 ไม่

พิพากษาแก่เป็นว่า ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายนั้น จำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์.

(ธานีศ เกศวพิทักษ์-วิชัย วิวิตเสวี-พิทักษ์ คงจันทร์)

ศาลอาญา - นายธนิต ภูริเวทย์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง กุลบุปผา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ